

< 채점기준 >

문제1의 1. (20점)

가. 쟁점 (2점)

- 채권자대위소송에서 피보전채권의 흠으로 소각하 판결이 확정된 이후, 채권자가 채무자를 상대로 피보전채권의 이행을 구하는 소송을 제기하는 것이 기판력에 저촉되는지 여부

나. 채권자대위소송의 법적 성격 (3점)

- 법정소송담당설 : 피보전채권은 원고적격의 문제, 피대위채권은 소송물로서 본안판단의 문제

다. 채권자대위소송에서 피보전채권의 흠으로 소각하 판결이 확정된 경우 기판력의 발생 범위 (10점)

: 대법원 2014. 1. 23. 선고 2011다108095 판결

민사소송법 제218조 제3항은 '다른 사람을 위하여 원고나 피고가 된 사람에 대한 확정판결은 그 다른 사람에 대하여도 효력이 미친다.'고 규정하고 있으므로, 채권자가 채권자대위권을 행사하는 방법으로 제3채무자를 상대로 소송을 제기하고 판결을 받은 경우 채권자가 채무자에 대하여 민법 제405조 제1항에 의한 보존행위 이외의 권리행사의 통지, 또는 민사소송법 제84조에 의한 소송고지 혹은 비송사건절차법 제49조 제1항에 의한 법원에 의한 재판상 대위의 허가를 고지하는 방법 등 어떠한 사유로 인하였든 적어도 채권자대위권에 의한 소송이 제기된 사실을 채무자가 알았을 때에는 그 판결의 효력이 채무자에게 미친다고 보아야 한다. 이때 채무자에게도 기판력이 미친다는 의미는 채권자대위소송의 소송물인 피대위채권의 존부에 관하여 채무자에게도 기판력이 인정된다는 것이고, 채권자대위소송의 소송요건인 피보전채권의 존부에 관하여 당해 소송의 당사자가 아닌 채무자에게 기판력이 인정된다는 것은 아니다. 따라서 채권자가 채권자대위권을 행사하는 방법으로 제3채무자를 상대로 소송을 제기하였다가 채무자를 대위할 피보전채권이 인정되지 않는다는 이유로 소각하 판결을 받아 확정된 경우 그 판결의 기판력이 채권자가 채무자를 상대로 피보전채권의 이행을 구하는 소송에 미치는 것은 아니다.

라. 사안의 해결 (5점)

- 후소는 기판력에 저촉되지 않으므로 乙의 주장을 배척하여야 한다.

문제1의 2. (20점)

가. 사해행위의 취소 및 원상회복의 범위 (10점)

- 저당권이 설정되어 있는 부동산이 사해행위로 이전된 경우에 그 사해행위는 부동산의 가액에서 저당권의 피담보채권액을 공제한 잔액의 범위 내에서만 성립한다고 보아야 하므

로, 사해행위 후 변제 등에 의하여 저당권설정등기가 말소된 경우 위 잔액의 범위 내에서만 사해행위를 취소하고 가액배상을 명하여야 한다는 것이 판례의 입장임

나. 법원의 판단 (5점)

- 판례는 사해행위인 계약의 전부취소와 부동산 자체의 반환을 구하는 청구취지 가운데에는 위와 같이 일부취소를 하여야 할 경우 그 일부취소와 가액배상을 구하는 취지도 포함되어 있다고 보고 있으므로, 청구취지의 변경이 없더라도 바로 일부취소 및 가액배상을 구할 수 있다는 입장임

다. 사안의 해결 (5점)

- 따라서 갑이 매매계약을 전부 취소하고 병 명의의 소유권이전등기말소를 구하는 종전의 청구취지를 그대로 유지할 경우에도, 법원은 부동산의 가액에서 근저당권의 피담보채무를 공제한 잔액의 범위 내에서 매매계약의 일부취소와 가액배상을 명하여야 하며, 이는 처분권주의 위반이 아님

문제2의 1. (30점)

가. 쟁점 (2점)

- 보조참가인의 항소의 적법성, 보조참가인의 항소에 대한 피참가인의 항소취하의 적법성, 보조참가의 참가적 효력

나. 보조참가인의 항소의 적법성 (8점)

- 보조참가인은 피참가인의 승소를 위하여 필요한 소송행위를 자기의 이름으로 할 수 있으며, 이러한 참가인의 소송행위는 피참가인 자신이 행한 것과 같은 효력이 생긴다. 그러나 참가 당시의 소송진행 정도에 따라 피참가인도 할 수 없는 소송행위는 참가인도 할 수 없음. 따라서 보조참가인은 피참가인의 상소기간 내에서 자기의 이름으로 상소할 수 있음
- 사안에서 보조참가인인 을은 피참가인인 병의 항소기간 내(판결정본 송달일로부터 2주 이내)에 항소를 제기하였으므로 을의 항소는 적법하며 병에게 효력이 있음

다. 피참가인의 항소취하의 적법성 (5점)

- 참가인은 피참가인의 행위에 어긋나는 소송행위를 할 수 없으며, 참가인의 행위와 어긋나는 행위를 피참가인이 뒤에 한 경우에도 참가인의 행위는 무효가 됨. 따라서 참가인이 제기한 항소를 피참가인이 취하할 수 있음.
- 사안에서 피참가인인 병이 보조참가인인 을이 제기한 항소를 취하한 것은 적법

- 라. 후소에서 을의 위 주채무 변제소멸 주장이 적법한지 여부(보조참가의 참가적 효력) (15점)
- 참가적 효력 : 피참가인이 전소에서 패소한 뒤에 피참가인이나 참가인이 소송을 제기하는 경우 피참가인에 대한 관계에서 참가인의 전소의 판결내용이 부당하다고 주장할 없는 구속력
 - 참가적 효력의 범위 : 판결주문에 대해서뿐만 아니라 판결이유 가운데 패소이유가 되었던 사실상.법률상 판단으로서 참가인이 피참가인과 공동이익으로 주장하거나 다룰 수 있었던 사항에 미침
 - 참가적 효력의 배제 : 그러나 참가인의 행위가 피참가인의 행위와 어긋나게 되어 효력을 가지지 않게 된 경우, 피참가인이 참가인의 행위를 방해한 경우 등에는 참가적 효력이 배제됨
 - 사안에서, 주채무 변제소멸 여부에 관한 주장은 전소에서의 판결이유 가운데 패소이유가 되었던 부분에 대한 판단으로서 참가인인 을과 피참가인인 병이 공동이익으로 주장할 수 있었던 사항에 해당하여 참가적 효력이 발생하는 범위임. 그러나 피참가인인 병인 보조참가인인 을이 제기한 항소를 취하한 것은 피참가인이 참가인의 행위를 방해한 경우에 해당하여 참가적 효력이 배제됨. 따라서 후소에서 을은 주채무 변제 소멸 사실을 주장할 수 있음

문제2의 2. (10점)

가. 쟁점 (2점)

- 보조참가인이 참가신청을 취하한 경우의 참가적 효력 유무

나. 보조참가인이 참가신청을 취하한 경우의 참가적 효력 (8점)

- 참가인은 참가신청을 취하할 수 있지만, 그러한 경우에도 참가적 효력이 미침. 앞서 본 바와 같이 참가적 효력은 판결주문 뿐만 아니라 판결이유 중 판단에도 미침
- 따라서 병이 후소인 구상금청구소송에서 주채무가 변제로 소멸하였다는 주장을 하는 것은 전소의 참가적 효력에 따른 판결이유 중 판단에 반하므로, 적법하지 않음

문제2의 3. (20점)

가. 사문서의 진정성립과 증명책임 (15점)

- 처분문서의 경우 진정성립이 인정되면, 법원은 그 기재내용을 부정할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없는 한 그 처분문서에 기재된 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정해야 함, 지급각서는 사문서로써 처분문서임.

- 문서제출자(거증자)는 사문서의 진정성립을 증명해야 함
- 사문서의 진정성립에 관하여 판례는 인영의 진정이 인정되면 날인의 진정이 사실상 추정되고, 날인의 진정이 인정되면 민사소송법 제358조에 의하여 문서 전체의 성립의 진정이 추정된다는 입장(2단계의 추정)에 있음 인영의 진정 인정 시 날인의 진정 (사실상) 추정
- 사문서에 날인된 작성명의인의 인영이 그의 인장도용이 증명되면, 문서제출자의 상대방은 날인의 진정을 깨기 위해 인장도용, 자격모용 등의 사실을 적극적으로 증명해야 하며, 그 증명에 성공한 경우 사문서의 진정성립은 추정되지 않으므로, 문서제출자는 날인행위가 작성명의인으로부터 위임받은 정당한 권원에 기한 것이라는 사실을 증명해야 함

나. 사안의 해결 (5점)

- 사안에서 법원은 정이 날인할 때 병으로부터 적법한 권한을 위임받아 날인한 것이라는 점에 대하여 확신을 갖지 못하였으므로 병이 '인장도용 사실' 등에 대한 증명에 성공하고 갑이 '날인행위가 병으로부터 위임받은 정당한 권원에 의한 것이라는 사실'을 증명하지 못한 것임
- 따라서 지급각서의 진정성립은 추정되지 않으므로, 법원은 지급각서를 증거로 하여 병의 연대보증사실을 인정할 수 없음